

1500038-68.2022.8.26.0550

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... pode justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1776115/T0, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 21/05/2021).

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500038-68.2022.8.26.0550 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500038-68.2022.8.26.0550 - 2022/000019

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

MATEUS DOS SANTOS SILVA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, , assim porque, no dia 07 de janeiro de 2.022, por volta das 11:30 horas, na Avenida 22 BR, defronte ao nº 356, Chácara Lusa, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 22 (vinte e dois) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando aproximadamente 13,70 gramas, e 03 (três) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol, totalizando aproximadamente 11,30 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 22/24, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 18 de abril de 2022.

Em instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, inviabilizando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da dedicação ao tráfico, devendo ser a reprimenda cumprida em regime prisional inicial fechado. Requereu, por fim, a decretação do perdimento da quantia apreendida em poder do acusado. Já a ilustre Defensora Pública sustentando insuficiente a prova produzida, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação pela imputação inicial, pugnou fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fixação de regime prisional inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a restituição dos valores apreendidos, facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 137/139, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetraidrocannabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha. Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em Juízo, o acusado negou a prática do delito que lhe é irrogado na denúncia, afirmando que na ocasião dos fatos estava no local onde abordado tão somente para a aquisição de entorpecente, sendo usuário, negando tenha empreendido fuga momentos antes de ser abordado por policiais civis.

Todavia, a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida.

De fato, o investigador de polícia Jorge Luiz, que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, esclareceu que já tinha anteriormente, em novembro de 2021, constatado a prática do comércio ilícito por parte do acusado no mesmo local, em razão de "campanas" realizadas, observando que naquela ocasião ele conseguiu empreender fuga no momento em que buscaram abordá-lo, disto resultando a expedição de um mandado de prisão temporária. No dia dos fatos descritos na denúncia, retornaram ao local em função de notícia de que ele voltara à prática do mesmo delito, ocasião em que efetivamente o avistaram, tendo, também dessa vez, empreendido fuga, durante a qual jogou ao solo algumas porções de cocaína e maconha, mas desta feita acabou sendo detido, com alguma quantia em dinheiro.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento do Policial Civil envolvido nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que

os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Como se vê, além da observação de que o acusado já realizava no mesmo local a prática do delito, diante de investigação realizada anteriormente, que deu ensejo à expedição de mandado de prisão temporária (Processo 1511740-60.2021.8.26.0510 - 1ª Vara Criminal de Rio Claro), estava ele ainda em liberdade provisória, igualmente em função de prisão em flagrante por conta de tráfico de entorpecentes (Processo 1501611-09.2018.8.26.0510 - 3ª Vara Criminal de Rio Claro), tendo sido avistado no mesmo local, conhecido ponto de venda de entorpecente, portando vinte e duas porções de cocaína e três de maconha, circunstâncias que compõem substrato probatório que permite seguro juízo de convicção sobre a posse a destinação mercantil, sendo incontornável o acolhimento da pretensão acusatória, inclusive com a incidência da pena de perdimento sobre o valor apreendido com ele, no momento em que estava realizando a atividade ilícita.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, sendo o acusado primário e não sendo expressiva a quantidade da substância entorpecente apreendida, possível seja a pena-base fixada no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. É que as circunstâncias acima indicadas, ostentando ademais o acusado registro de ato infracional equiparada desde o tempo em que ainda adolescente, revelam inequívoca dedicação a esta atividade ilícita, demonstrando que não se trata de nenhum "neófito", a quem se destina a minorante.

Se os registros criminais não se prestam a afastar a primariedade, podem servir de fundamento para a compreensão da vida anteacta, com dedicação à atividade criminosa, inclusive os atos infracionais praticados, enquanto adolescente.

A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUTOR. VERIFICAÇÃO.

SÚMULA N. 7 DO STJ. ATOS INFRACIONAIS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do

tribunal de origem implica revolvimento fático-probatório dos autos. 2. O registro

de atos infracionais pode ser considerado como elemento de convicção de que o

agente se dedica a atividade criminosa e, portanto, pode justificar o afastamento

do redutor do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp

1776115/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 21/05/2021).

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.

11.343/2006. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO. 1. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no

sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente

quando análogos ao delito de tráfico, são aptos a afastar a incidência do benefício

(AgRg no RESp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe

23/10/2017). (...) (AgRg no HC 658.774/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, Quinta Turma, DJe 07/05/2021).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão

acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06, CONDENO o

acusado MATEUS DOS SANTOS SILVA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica

do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento da

quantia apreendida, já que comprovadamente obtida com a venda do entorpecente, nos

termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, e considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF) e o que disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, proferida pelo Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras. Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o

fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA